

1500876-58.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... condenação do réu Pedro pelo crime de tráfico de entorpecentes e a absolvição do acusado Marthus.

A Defesa pleiteou a absolvição de ambos os réus, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 ao acusado Pedro e, em caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55 - Bairro dos Alemães

CEP: 13419-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3018 - E-mail: piracicaba1cr@tjsp.jus.br

1500876-58.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500876-58.2022.8.26.0599

Controle nº

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

MARTHUS ALEXANDRE CAMARGO DE TOLEDO e outro

Vistos,

PEDRO HENRIQUE DA ROCHA e MARTHUS ALEXANDRE CAMARGO DE TOLEDO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 12 horas e 20 minutos, na rua Pau Brasil nº 100, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca, em concurso, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 106 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 121,4g; 17 invólucros de plástico contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 11,2g; e 4 invólucros de plástico contendo maconha (fragmentos vegetais constituídos de folhas, inflorescência, caules e frutos, contendo a substância entorpecente Tetrahydrocannabinol - THC), com peso bruto aproximado de 18,1g (cf. laudo de constatação de fls. 50/55, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 123/125 e fotografia de fls. 17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra, a denúncia, que policiais militares patrulhavam pelo local indicado, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com a motocicleta de placa FJV8H18, que era pilotada por Pedro e ocupada por Marthus na garupa (fls. 3). Ao notarem a presença da polícia, os acusados empreenderam fuga com a motocicleta.

Durante a perseguição, Marthus apeou da motocicleta em movimento; logo depois, Pedro perdeu o controle de seu conduzido.

Narra, ademais, que ambos foram contidos e, na busca pessoal levada a efeito em Pedro, se verificou que ele trazia consigo as porções de droga já discriminadas, além de R\$ 126,45 provenientes do comércio ilegal.

Consta, por fim, que as circunstâncias narradas evidenciaram que Pedro e Marthus atuaram juntos e que as substâncias apreendidas pertenciam a ambos e se destinavam ao tráfico.

Os réus foram notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 212 e 214). Defesa preliminar apresentada às fls. 217/224. Após, a denúncia foi recebida (fls. 237/238) e os réus foram citados (fls. 277 e 278).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu Pedro pelo crime de tráfico de entorpecentes e a absolvição do acusado Marthus.

A Defesa pleiteou a absolvição de ambos os réus, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 ao acusado Pedro e, em caso de condenação por tráfico, o reconhecimento do privilégio em relação a este acusado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede, em parte.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos: 1) boletim de ocorrência de fls. 09/12; 2) auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e fotografia de fls. 17; 3) laudo de constatação de fls. 50/55 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 177/179, os quais atestaram resultados positivos para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) em relação às substâncias apreendidas e 4) BOPM de fls. 263/270.

A autoria foi revelada pela prova oral em relação ao acusado Pedro, nos termos da manifestação da representante do Ministério Público. Senão vejamos:

Na fase informativa (fls. 05/06), o réu Pedro Henrique exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), Pedro confessou os fatos, alegando que Marthus não tinha ciência que ele estava com a droga, alegou ser usuário compulsivo e que foi até o local comprar mais drogas porque fez uso do último pino que tinha com amigos; alegou que comprou a droga para ele e para amigos e que encontrou com Marthus e deu-lhe uma carona; começou a correr quando se deparou com a viatura; Marcos apertou o freio e pulou e depois quando continuou a fuga se deparou com várias viaturas e uma delas "lhe atropelou" e então caiu ferido e desacordado. Quando acordou, já estava com os policiais. Alegou não ser traficante, que estava trabalhando e que tinha acabado de comprar sua moto. Comprou as drogas 2 minutos antes da abordagem; comprou 108 pinos de cocaína e já tinha cheirado 2 quando comprou e 138 pedras de crack e 4 ou 5 parangas (maconha). Faz uso toda hora, mal almoça e toma café, já faz uso. A droga que comprou daria para um dia e meio, dois dias. Pagou 530 da cocaína e 590 de crack e todo o dinheiro foi na droga, não tinha nenhum dinheiro consigo. Quando acaba a droga fica sem. Recebeu o pagamento, tirando em faixa de R\$ 2.500 mais ou menos e que gastou mil reais de drogas, pagou o aluguel, pagando R\$ 500 e guardou uns 500 reais. Depois que acaba o dinheiro, faz uso com amigos. Conheceu Marthus um dia antes, dia 15, e que encontrou com ele no Bosque, quando o depoente estava usando drogas; estava em frente a um bar, na Rua Dez. No dia seguinte, encontrou com Marthus no Industrial, porque estava indo embora; e então voltou para levar ele para o Bosque. Comprou a droga perto de um parquinho, no Bosque dos Lenheiros, antes de encontrar o Marthus. Dirigiu por mais ou menos 2/3 minutos e encontrou Marthus e então voltou, mesmo não sendo caminho do depoente. Estava indo para sua casa, quando encontrou Marthus, para sua casa, que era outro sentido que Marthus estava. Ele estava na Avenida, mas não sabe o nome, a pé; o depoente parou para conversar com Marthus e ele pediu uma carona que estava

vindo da Balbo, bairro boa esperança; não sabe como do bairro Boa esperança para o industrial. Marthus pulou da moto, dizendo que ele estava de saidinha. Não chegou a usar drogas com Marthus. Faz uso de drogas desde os 10/11 anos. A quantidade pegou porque os amigos deram dinheiro, que estavam em quatro. Mas sozinho faz uso de 10/15 pedras por dia. Usaria aquela droga com os amigos. Nenhum deles lhe acompanhou porque estava sem habilitação. Na infância tem uma passagem como "usuário" e a outra passagem era do carro roubado que tinha na casa de sua namorada. Na delegacia ficou em silêncio porque não queria falar, estava "louco de drogas", estava em efeito da droga. Alegou que foi abordado pelos policiais que deram depoimento hoje.

Por sua vez, ouvido na fase extrajudicial (fls. 07/08), Marthus Alexandre negou o crime. Disse que, no dia dos fatos, estava na casa de sua madrinha e pegou uma carona com o acusado Pedro, para ir até o bairro Mario Dedini. Afirmou que não conhecia Pedro e sequer sabia o seu nome. Relatou que durante o percurso passaram a ser perseguidos por policiais militares, mas Pedro não parou a motocicleta e então optou por pular do veículo. Asseverou que não sabia que Pedro carregava drogas com ele e negou qualquer envolvimento com o tráfico, reafirmando que apenas estava aproveitando uma carona.

Interrogado em juízo (gravação), Marthus disse que estava na sua quarta saída temporária e que estava visitando alguns parentes e ia na casa de sua madrinha e então pediu para Pedro carona, para ele deixar na entrada do Bosque; Pedro estava correndo muito e em seguida apareceu os policiais da Rocam e que então tentou apertar o freio, mas não conseguiu e então pulou da moto. Foi abordado e negou ter algo errado, que estava somente visitando seus parentes. Foi levado para o pronto socorro, passando por onde Pedro estava; então foi levado para a delegacia. Foi então que viu os policiais na delegacia contando os pinos de cocaína, achando que era de outra abordagem. Pedro estava passando para o Industrial indo em direção a avenida do Sesi, em direção ao Bosque. O Bairro Industrial é vizinho do Bosque; estava vindo da casa da sua irmã, que fica no Bairro Industrial. A distancia era cinco ou seis quarteirões. Não conhecia Pedro, conheceu um dia antes, da rua da casa de sua irmã, que mora no Bosque. A moto dele estava indo sentido ao Bosque, quando pediu carona. Não faz uso de drogas. Tinha saído na ultima saidinha, dia 14 e deveria voltar no dia 20.

As versões dos acusados são contraditórias e afastadas pelas provas dos autos, as quais comprovaram que ambos cometeram o delito que lhes foi imputado na denúncia, sendo a negativa totalmente inverossímil e esvaziada de qualquer prova ou indício. Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e sob o crivo do contraditório nesta audiência (gravação), o policial militar Rodrigo Fernandes Santiago disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Bosque dos Lenheiros e avistaram uma motocicleta dois indivíduos, sendo que o garupa estava sem capacete. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os acusados empreenderam fuga com a moto, dirigindo perigosamente pelas ruas do bairro e cometendo diversas infrações de trânsito. Relatou que, na rua Arlindo Lopes, Marthus, que estava na garupa, pulou do veículo ainda em movimento, caindo no chão e sendo detido pelo seu parceiro SD PM Biagi. Continuou no acompanhamento de Pedro, que seguia em fuga na condução da motocicleta. Contudo, em dado momento, ao avistar outra viatura que vinha em apoio, o acusado perdeu o controle e caiu. Declarou que os dois acusados foram revistados e Marthus não trazia nada de ilícito, porém, Pedro carregava uma bolsa na cintura, na qual haviam 106 pinos de cocaína, 4 porções de maconha e 17 pedras de "crack", além de R\$ 126,45 em espécie. Não conhecia nenhum deles antes dos fatos; abordou Pedro, condutor na moto e que ele informou que pretendia vender a droga no Bosque dos Lenheiros. Marthus foi abordado pelo seu colega. A confissão pelo Pedro foi espontânea. O local do início do acompanhamento da moto foi o "trio" que é um ponto forte da venda de drogas. O que motivou a abordagem é que quando a moto lhe visualizou empreendeu fuga e então visualizaram que o garupa estava sem capacete. A bolsa com as drogas era escura e era cocaína, crack e maconha e não lembra com detalhes a quantidade, que era grande, superior ao consumo. O local da abordagem é uma comunidade, e dificilmente há câmeras no local; não possuem câmeras consigo, ainda não chegou esta tecnologia no local. Pedro alegou que o dinheiro que

portava era proveniente da venda, que seria destinado ao troco da venda de drogas. Pedro não disse trabalhar de forma lícita. Pedro alegou que estava indo vender as drogas, mas não disse se naquele dia já tinha vendido antes. Pedro disse que Marthus estava indo com ele até o "trio" para "prestar o apoio", mas não especificou o que seria esse apoio.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em juízo (gravação) pelo policial militar Gabriel Casemiro Biagi, acrescentando que foi o responsável por abordar Marthus, que tinha pulado da moto em movimento.

Questionado, Marthus disse que tinha falado para Pedro parar e ele não parou. Não conhecia nenhum deles antes dos fatos. Marthus alegou que pediu uma carona para Pedro. Quando chegou ao local em que Pedro tinha sido abordado, Pedro já estava sendo socorrido. Marthus disse que estava de "saidinha". Não presenciou a droga sendo encontrada com Pedro e não sabe se mais alguém presenciou, mas no local havia mais policiais. Pedro "trombou" com uma viatura de frente, quando caiu com a moto. Quando chegou tinha diversas viaturas no local. Pedro tinha algo na cintura, mas não sabe o que era.

É crível que Pedro estivesse indo em direção ao Bosque, em direção ao ponto de venda de drogas, conforme, inclusive alegado pela testemunha, conforme a versão do acusado Pedro à testemunha.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. No entanto, em relação ao réu Marthus as versões dos policiais não são suficientes para concluir que Marthus soubesse que Pedro estava com a droga e ainda que de fato lhe auxiliaria na venda da drogas de alguma forma.

O réu Pedro não trouxe nenhum fato indicativo de perseguição gratuita contra ele por parte da polícia, tendo ambos declarado que sequer os conheciam antes dos fatos. Note-se que embora Pedro tivesse alegado já ter sido abordado anteriormente pelas testemunhas, não há nada nos autos que comprove essa anterior abordagem. Não é crível que a testemunha mentisse em juízo, afirmando que Pedro confirmou que pretendia fazer a venda da droga. Ademais, a expressiva quantidade de entorpecentes adquirida não condiz com o preço que alegou ter pago.

No mais, presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado Pedro em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que Pedro trazia consigo e transportava as substâncias entorpecentes apreendidas e descritas na denúncia, as quais eram destinadas ao comércio e consumo de terceiros.

De fato, Pedro agiu de forma suspeita ao avistar os policiais, se evadindo do local com a motocicleta em alta velocidade, na tentativa de se evitar uma abordagem. Frustrada a tentativa de fuga, Pedro foi abordado e revistado, sendo as drogas encontradas na posse do réu Pedro. Não há, dessa forma, dúvida alguma de que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado, bem assim que eram destinados ao tráfico.

A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos revela o destino mercantil, pois incompatível com a situação de mero usuário.

Além disso, com Pedro também foi apreendida a quantia de R\$ 126,45, em notas trocadas (fotografia de fls. 17), o que, aliado à falta de comprovação idônea por parte da Defesa, da origem lícita, faz presumir decorrer do comércio ilegal e confirma o destino mercantil dos entorpecentes, ensejando, inclusive, seu perdimento para a União.

Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem embaladas em porções individuais, da forma como comumente são comercializadas.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos

entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu Pedro pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Embora existam fortes indícios de que Marthus também estaria envolvido com o tráfico, tanto que Pedro disse a uma das testemunhas hoje ouvida que Marthus estaria em seu apoio, não há provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se, no presente caso, "in dubio pro réu" em relação a Marthus.

Passo à individualização das penas de Pedro.

O réu Pedro é primário, mas ostenta antecedentes criminais na infância, demonstrando personalidade voltada para a prática delituosa. No entanto, deixo de aumentar a pena base para não configurar "bis in idem", eis que tal circunstância será analisada quando da verificação da possibilidade ou não de aplicação do provilégio.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis. A diversidade e quantidade de drogas, embora expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, aplico-lhes as penas mínimas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para cada um.

Inexistem atenuantes.

Não há agravantes em relação ao réu Pedro.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06.

No que diz respeito a Pedro, embora primário, possui condenação na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de receptação (fls. 196/198 - Processo nº 0031208-90.2012.8.26.0451), com aplicação de medida de liberdade assistida, o que, aliado ao fato de não ter comprovado exercer atividade lícita, trazer consigo e manter em depósito expressiva quantidade e diversidade de drogas, demonstra que vem se dedicando às atividades criminosas e fazendo do crime o seu meio de vida.

Tal fato demonstra que o réu tem total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou delinquindo.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se dedicado às atividades criminosas desde a adolescência, não comprovando atividade lícita, além de trazer consigo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, sendo uma delas (o crack), uma das mais nocivas ao ser humano, causando grande dependência.

No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, há diversos julgados, inclusive do C. STF e C. STJ:

"EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Ação penal com trânsito em julgado para afastar a incidência da causa especial de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Constrangimento ilegal não caracterizado. Agravo ao qual se nega provimento. 1. segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena pelo delito de tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. Para negar a redutora prevista na Lei de Drogas, o Superior Tribunal de Justiça apontou, no acórdão condenatório, que o paciente possui condenações por atos infracionais anteriores. Embora esses registros criminais não possam ser utilizados como maus antecedentes, tampouco como reincidência, nada impede que o seja como prova da dedicação do acusado à atividade criminosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF - HC 211261 AgR. Primeira Turma. Relator(a): DIAS TOFFOLI - J. 11/04/2022.) - g.n.

"EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF - HC 192147. Primeira Turma. AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI - j. 24/02/2021) - g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei

n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, os fatos em análise datam de 19/3/2021, em que o acusado foi surpreendido na posse de 149,8g (cento e quarenta e nove gramas e oito decigramas) de crack e 481,75g (quatrocentos e oitenta e um gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha e, consoante a folha de antecedentes criminais acostada aos autos, em 26/3/2021, foi cumprida a medida socioeducativa a ele imposta pela prática de ato infracional análogo ao delito do art. 157, § 2º, II, do CP, além da prática de diversos outros atos infracionais, incluindo a apuração de ato análogo ao crime em apreço, o que justifica o afastamento do pretendido redutor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no HC n. 724.241/MG. Sexta Turma. relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro - J. 9/8/2022) - g.n.

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso dos autos, em que pese a Corte de origem invocar a quantidade e natureza de drogas para majorar a basilar e afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, de per si, configuraria indevido bis in idem, verifica-se que ainda invocou fundamento para afastar a referida causa especial de diminuição de pena que está em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência admite que sejam invocadas anotações infracionais pretéritas para aferir a dedicação do acusado a atividades criminosas, notadamente diante da grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, tratando-se de "227,78 gramas de maconha e 13,2 gramas de cocaína" (fl. 272). III - Com efeito, tendo a Corte assentado que "o acusado possui anotação pela prática de ato infracional análogo à prática do tráfico de drogas (proc. 0006763-36.2019.8.26.0136 fls. 63)" (fl. 272), evidenciando ser registro recente que, somado às demais circunstâncias do caso concreto, torna inviável entender de forma contrária às instâncias ordinárias quanto à dedicação do agravante a atividades criminosas, pois demandaria aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. IV - Ressalte-se, por oportuna, que ao contrário do esposado no parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão da ordem para reconhecer o privilégio, a dedicação a atividades criminosas não decorreu unicamente da quantidade e diversidade de drogas, ou com base em ações penais em curso, mas sim em face da existência de registro de antecedente infracional específico que, somado às demais circunstâncias fáticas, evidenciam a dedicação do agravante ao comércio espúrio. V - Por fim, tem-se que o regime mais gravoso foi devidamente justificado na grande quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida que, na forma do art. 42 da Lei de Drogas e 33, § 2º, b e § 3º, do CP, legitima o recrudescimento do regime inicial, ainda que o paciente seja tecnicamente primário e tenha sido condenado a pena inferior a oito anos de reclusão. Precedentes. VI - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC n. 733.091/SP, Quinta Turma. relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) - j. 21/6/2022) - g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,913KG (UM QUILO E NOVECIENTOS E TREZE GRAMAS) DE MACONHA E 8G (OITO GRAMAS) DE COCAÍNA. PETRECHOS E ANOTAÇÕES RELATIVAS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABITUALIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que "atos infracionais praticados pelo agente quando



adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal" (HC n. 650.819/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021). 2. Tendo o Tribunal de origem indicado a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, no caso concreto, essa indicação, associada à apreensão de elevada quantidade de drogas - aproximadamente 1,913kg (um quilo novecentos e treze gramas) de maconha e 8g (oito gramas) de cocaína -, petrechos e anotações relativas ao tráfico de entorpecentes, em conjunto, denota habitualidade delitiva apta a afastar a aplicação da causa redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp n. 1.948.298/TO, Sexta Turma. relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro - j. 5/4/2022) - g.n.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes que os pacientes se dedicam ao comércio espúrio, com fulcro nos elementos constantes dos autos, sobretudo no fato de registrarem atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a", do CP. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC n. 711.617/SP. Quinta Turma. relator Ministro Ribeiro Dantas - j. 8/2/2022) - g.n.

Incabível, assim, o privilégio.

Ainda em relação ao réu Pedro, quanto ao regime de pena, elejo o semiaberto, eis que a quantidade de droga, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância e de se tratar de traficante de maior envergadura. No entanto, a pena é superior a quatro anos e inferior a oito e, por outro lado, conforme exposto, o réu vinha reiterando nas atividades criminosas, o que justifica a eleição do regime intermediário.

Ademais, o crime de tráfico de drogas tem graves consequências, fomentando a prática de vários outros delitos, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Necessária, assim, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos, estas também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato e, considerando que já vem traficando há algum tempo, desde que era menor de idade, muito provavelmente continuaria a realizar o nefasto comércio.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas três meses e doze dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu PEDRO HENRIQUE DA ROCHA a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário

mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06; e  
2) ABSOLVO o réu MARTHUS ALEXANDRE CAMARGO DE TOLEDO nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado nos autos que a quantia apreendida em poder do acusado Pedro é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu Pedro possui envolvimento pregresso com a prática de ato infracional análogo ao crime de receptação e, ao atingir a maioridade, continuou a delinquir, dessa vez no grave crime de tráfico de drogas. Ademais, uma das drogas que ele comercializava ("crack") é considerada mais nociva ao ser humano, causando grande dependência e destruindo famílias e vidas, configurando-se, desta forma, a intensa periculosidade da dupla e seu desprezo pela sociedade. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, as quais são necessárias para garantia da ordem pública e ficam, assim, mantida em relação ao acusado Pedro.

Recomende-se o réu Pedro no cárcere em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Ante a absolvição do acusado Marthus expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se e Cumpra-se.

Piracicaba, 27 de setembro de 2022.

Miriana Maria Melhado Lima Maciel  
Juíza de Direito  
Assinatura digital à margem Direita